

1501145-80.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... réu demonstram como o réu coordenava o tráfico, ordenava o fracionamento da droga, a contabilidade do tráfico e ainda há indicação de outros membros que integravam a associação ao tráfico e atividade de cada um deles, com estabilidade. Ademais, há foto da droga e como ela foi cortada.

Ressalta-se que o crime do art. 35 da Lei 11.343/06, dispõe: associarem-se duas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501145-80.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2161993/2022 - DISE-DEL.SEC.SANTO ANDRE, CL9144-2/2022 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS ALBERTO SERRANO

Réu Preso

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou CARLOS ALBERTO SERRANO, qualificado nos autos, como incurso nos arts. 33, caput e art. 235 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 14 de junho de 2022, na Comunidade AABB, nesta cidade e comarca, associou-se, de maneira estável e duradoura, com Lucas Pimentel Serrano, Robson de Oliveira Pereira, Alisson Henrique Carvalho Almeida e Patrick Vinicius Cardoso, para praticar o crime de tráfico ilícito de drogas. Consta ainda que no dia 14 de junho de 2022, na Rua dos Algonquinos, nº 476, Jardim do Estádio, nesta cidade e comarca, o denunciado, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 48,2 quilogramas de "maconha", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: A "Operação Sufoco" foi deflagrada

pela polícia civil para investigação e prisão dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região conhecida como "Comunidade AABB" em Santo André. Nos autos nº 1503576-45.2022.8.26.0554 foram determinadas diversas buscas e apreensões para as residências relacionadas aos investigados, dentre eles, o denunciado, conhecido informalmente como "Bocão". Segundo o apurado, o denunciado CARLOS, Lucas Pimentel Serrano, Robson de Oliveira Parreira, Alisson Henrique Carvalho Almeida e Patrick Vinicius Cardoso, de forma estável e permanente, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas nas dependências da Comunidade AABB. Realizadas as buscas e apreensões na residência do denunciado e demais comparsas, foram localizadas drogas e veículos automotores utilizados para a distribuição. No mais, as conversas travadas entre o denunciado e os demais, localizadas no celular de Lucas e Robson, permitiram a identificação da função de cada um na associação para o tráfico. O denunciado é responsável pela aquisição das drogas em peças grandes e determinação da quantidade de substância a ser fracionada para venda. Patrick Vinicius Cardoso é responsável pelo fracionamento em porções. Lucas Pimentel Serrano é responsável pelo fracionamento e distribuição das drogas em pontos de venda. Robson de Oliveira Parreira é responsável pelo gerenciamento de valores arrecadados, venda de drogas e controle de outros vendedores. Por sua vez, Alisson Henrique Carvalho Almeida é o gerente da venda na comunidade e integrante do PCC. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, policiais civis ingressaram no local. A diligência foi acompanhada pelo denunciado e pela testemunha Fernanda. Apurou-se que o denunciado tinha em depósito e guardava em uma cômoda localizada quarto, fragmentos de tijolos de maconha, duas facas, balanças de precisão, uma máquina de pagamento através de cartões, e três cadernos contendo anotações assemelhadas a contabilidade do tráfico de drogas e a quantia de R\$421,00. Além disso, em cima do guarda-roupas, foi localizada a quantia de R\$32.000,00 e na cama 02 celulares. Na cozinha do imóvel foram localizadas 01 guilhotina, com fragmentos de maconha, e embalagens para comercialização da droga. Os policiais apontaram ainda que o imóvel ao lado também seria pertencente ao denunciado, obtendo as chaves para acesso. No segundo imóvel, o denunciado tinha em depósito e guardava, 51 tijolos de maconha, com anotações nas embalagens semelhantes às localizadas em outros endereços objetos da investigação originária. O denunciado confessou informalmente a posse dos objetos apreendidos e das drogas. Em seguida, foi preso em flagrante. Pela quantidade e diversificação das drogas apreendidas, além da confissão informal, restou demonstrado que o denunciado visava o consumo de terceiros.

Fls. 111/114: foi determinada a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, a qual foi apresentada (fls.152/163), a denúncia foi recebida (fls.219/220) e o réu foi citado (fls.199).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos a vítima, testemunhas e em seguida, o réu foi interrogado.

O Representante do Ministério Público apresentou alegações finais orais e o defensor constituído do réu memoriais (fls. 259/269).

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Afasto a preliminar arguida, no caso em questão, entendo que não há qualquer nulidade no ingresso dos policiais na casa ao lado a do acusado, uma vez que pelos relatos das testemunhas ouvidas o ingresso foi autorizado, ainda que não fosse, a infração penal de tráfico de drogas é permanente e autoriza o ingresso no domicílio independentemente de mandado de busca e apreensão.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. *VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE*. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão

criminal. Precedentes. 2. Parte do objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 199.091/RJ. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 213852 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022)

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls.3), termo de ocorrência (fls.11/17), auto de exibição e apreensão (fls.18/20), laudo de constatação (fls.23/25), laudo do exame químico toxicológico (fls.133/135) bem como pelas provas orais colhidas no processo e provas dos autos do processo nº 1503576452022826055400000.

A autoria do acusado em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal. A informante Fernanda disse que os policiais entraram em sua residência e foi localizado dinheiro no local que era do lava rápido. Eles revistaram a casa e não foi localizada droga e nem arma. O dinheiro estava em cima do guarda roupa. Afirma que seu marido tem dois carros. Ao lado tem uma outra casa que é da família. E todos os familiares tem a chave. Não sabe se foi encontrada droga nesta casa. Não sabe do envolvimento do marido em tráfico. Não conhece o réu como "Bocão". Não sabe se Lucas tem apelido. Não conhece Robson, Alisson e Patrick. Não autorizou a entrada dos policiais no imóvel e não forneceu a chave para eles ingressarem no imóvel. O réu tem uma Hilux e uma XL. A moto é de Lucas. O Fox comprou com o dinheiro do lava rápido e estava na casa do lado.

A testemunha Gustavo disse foi chamado para cumprir mandado de busca e apreensão no local. Bateu diversas vezes e ninguém abriu. Arrombaram a porta. O réu reagiu, mas depois que viu o mandado não mais. No quarto dele tinha 2 porções de maconha. Foi localizada a importância de R\$ 32.000,00 em notas picadas. Existiam diversos apetrechos do tráfico como balança, embalagens, guilhotina. A namorada do réu deu a chave da casa do lado e lá foi encontrada a maconha. Localizou as chaves dos carros. E ela entregou a chave da casa. Não pediram mandado de busca e apreensão da casa vizinha, porque ela autorizou a entrada. A quantia de R\$ 32.000,00 eram em notas de R\$ 50,00. O réu disse que o dinheiro era dele. Na casa do réu não tinha condições de ter lava rápido e sim era a residência dele. Os dois pedaços de droga localizadas na casa do réu era igual a da casa vizinha. As facas apreendidas estavam com resquícios de maconha e a guilhotina é utilizada para cortar a droga. A balança estava no quarto do lado das facas. A guilhotina estava na cozinha. Existiam embalagens para droga. Ele confessou que a droga da casa vizinha era dele. Foram a casa vizinha em busca do Fox que era usado no transporte e comercialização da droga. O réu não forneceu a senha do celular dele. A testemunha Márcio foi na casa vizinha. Entregou a chave da casa vizinha para o pessoal do GOE. Os policiais não ingressaram na casa vizinha antes de localizarem a chave. Não sabe como se chegou ao acusado, pois não participou das investigações. Ficou sabendo do veículo Fox pelo pessoal da investigação.

A testemunha Márcio afirmou que a diligência foi presidida pela equipe 6. Foi cumprir o mandado de busca e apreensão no local. Foi localizado apetrechos do tráfico, guilhotina, facas, veículo Hilux e o Fox estava na casa ao lado. Na casa do lado foi localizada a maconha, Não entrou na casa do réu a princípio. Só ingressou no local depois que ele estava detido para pegar a chave da Hilux. Não se

recorda quem recebeu a chave da casa vizinha, o portão de lá foi aberto com o controle. Em fls. 170 a porta está arrombada, mas não fez isso e não sabe se foi alguém quem fez. Fls. 177 é a casa vizinha e este portão foi o que já estava aberto e lá estava o veículo Fox. Não revistou o veículo. Foi quem localizou a droga na casa, Ela estava no chão, no cômodo a direita da entrada. Estava em um saco de papelão. Acredita que era aproximadamente 40kg e ela exalava cheiro. O réu admitiu que a droga era dele. Dos policiais que realizaram a investigação, no dia estava no local apenas Breno. Não sabe dizer porque não foi pedido mandado de busca e apreensão da casa vizinha e porque não foi pedido perícia.

A testemunha César disse que o Inquérito Policial começou com a apreensão de drogas no Jardim Las Vegas e que seria de propriedade do réu. Realizou a investigação e o réu seria o gerente do ponto de venda da favela AABB e os veículos Peouget e Palio estariam envolvidos. Fez campana vários dias e observou que o réu foi ao local vários dias. Verificou o endereço do acusado e a movimentação do filho dele. Foi solicitada mandado de busca e apreensão na casa do acusado. Patrick e Lucas fracionavam a droga e quem determinava era Carlos. Não participou da busca e apreensão na casa do acusado. Estava na diligência na casa de outro menino. Fls. 108 dos autos 1503576452022826055400000, não chegou a ter acesso as conversa do Whatsapp de Carlos porque ele se recusou a fornecer a senha. Porém, no telefone do filho dele tinham várias conversas com o acusado e Carlos com Galo. Conversas para o filho fracionar a droga em diversos tamanhos. Fls. 121: viu a foto da maconha que Lucas cortou para mostrar como estava sendo feita no celular de Lucas. Fez várias campanas na frente da casa de Carlos e filmou ele saindo de sua casa e entrando na outra casa, Não há acesso de uma casa a outra. Ela fica no mesmo terreno. O mandado de busca e apreensão foi solicitado para o número 476 fundos. Era o local que via o acusado entrando. Fls. 177, autos 150114580202282605400000 é a residência onde foi localizada a droga. Esta casa é dos fundos. Os policiais disseram que a esposa de Carlos forneceu a chave e o controle. Os veículos apreendidos pelas conversas telefônicas eram utilizados para levar a droga para o ponto de venda. Não conseguiu tirar fotos do acusado com os demais investigados.

A testemunha Carlos Alberto disse que uma equipe da unidade apreendeu 5kg de droga, em um bairro em Santo André, Foi determinada ordem de serviço para identificar o responsável. Em contato com diversas pessoas conseguiu informação que a droga seria de "Bocão" que usava um veículo Hilux, "Galego", um veículo Peugeot, Patrick, um veículo Uno e "Japa". E a droga era vendida na comunidade AABB. O Delegado determinou diligências. Viu o veículo Peugeot, Palio Weekend, Uno e Hilux. Estava no local com César quando a Hilux tentou entrar na comunidade, o réu estacionou em uma travessa e desembarcou. Logo em seguida, apareceu o veículo Palio Weekend que está atrelado a "Japa". Não conseguiu captar imagens deles juntos. A Palio saiu pela outra travessa. Foi feita mais diligências e monitorou a distância, Carlos, Patrick, Robson e Japa. Patrick mudou de endereço um pouco antes da operação. Com as informações foram solicitados os mandados de busca e apreensão. A equipe se dividiu para cumpri-los. Na casa de Patrick foi localizada droga, na casa de Galo foi localizada maconha e cocaína. Na casa do acusado foram localizados ferramentas para o corte, embalagens da droga, dinheiro e na casa dos fundos 45 kg de maconha. Todos os tijolos estavam com números escritos, Cristiano e Breno foram no endereço do acusado. No monitoramento do acusado, não viu atividade de lava rápido na casa do réu. Teve acesso ao celular de Lucas e viu diversas conversas com o réu relacionadas ao tráfico, como cortar a peça (tijolo) e a quantidade de 5 que seria R\$ 5,00, a outra R\$ 10,00. Além disso, o réu é a pessoa que adquiria o entorpecente e abastecia o ponto de venda em relação a maconha. O filho é quem levava as informações para Patrick. O réu fala para o filho que tem que se reportar a ele e obedecer as regras. Tem conversas de Carlos com Lucas relativas a quantidade de drogas que tinha que cortar. Não tinha certeza que não havia acesso aos fundos pela casa de Carlos. O réu utilizava o veículo Hilux. Foram feitos vídeos ele entrando de uma casa em outra. Soube, posteriormente, que o acesso é só pelo lado externo. A namorada do réu deu a chave da outra casa e o controle.

Por fim, o réu, em seu interrogatório, aduziu que desconhece a droga apreendida em sua casa. Em 2011 montou uma estacionamento com estética automotiva. Em 2021, teve

êxito em uma ação judicial e recebeu aproximadamente R\$ 44.000,00. Começou a trabalhar em casa com veículos. A casa ao lado recebeu com seus irmãos como herança. A droga foi localizada lá. Não foi localizada nada em sua residência. Apenas o dinheiro, por volta de R\$ 32.000,00 que estava juntando. A casa ao lado estava a venda e ia lá de vez em quando mostrar a eventuais compradores. O endereço de sua casa é na Rua Algonquinos, nº476. A outra fica na Rua Amoritas, nº 25. Não há acesso de uma casa a outra. Não autorizou os policiais a ingressarem na casa ao lado. E Fernanda não forneceu a chave. Possui a Hilux há 4 anos e a comprou com dinheiro de uma indenização que recebeu. Pelo que soube o imóvel foi arrombado pelos policiais. Nunca frequentou a comunidade AABB. Frequentou o Restaurante do Peixe, o qual ia com a menina de seu novo relacionamento. Pois bem, a versão do réu restou ilhada frente as demais provas produzidas nos autos.

As testemunhas César e Carlos Alberto descreveram com detalhes como procederam as investigações que culminaram com os mandados de busca e apreensão na casa do réu e demais averiguados. Narraram a conduta do acusado e dos outros averiguados sendo que o réu seria o gerente do tráfico, ou seja, responsável pelo abastecimento de maconha na Comunidade AABB e coordenava como a droga deveria ser fracionada.

As testemunhas Márcio e Gustavo afirmaram como foi realizado o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do réu, onde a droga, guilhotina, faca com fragmentos da droga, embalagens e dinheiro foram localizados.

Assim, como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssonos no sentido de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia. Relataram detalhes das investigações e cumprimento dos mandados de busca e apreensão, logo, não há motivo para não considerar os depoimentos dos policiais.

Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENHIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020). Ademais, eventuais pequenas contradições nos depoimentos dos policiais são irrelevantes.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma:

As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim, é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca JUTACRIM-SP 67/311).

Acrescenta-se ainda que não se pode acreditar que os policiais resolvessem, do nada, acusar o réu da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse efetivamente participação no mesmo. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer. Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado.

Ressalta-se ainda que em casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir como testemunha, razão pela qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em consagrar a total impunidade. Ademais, a quantidade da droga, embora não seja exclusivo, constitui fator importante para a caracterização do tráfico (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção Repressão, Saraiva, 1992, pág. 182).

Consoante já se decidiu, "a apreensão de grande quantidade de drogas configura o animus de traficar, somente ilidível quando alegada a finalidade exclusiva de uso próprio, com robusto material probatório favorável ao mesmo" (STJ, Rec. Esp nº 163.640, rel. Min. Jorge Scartezini, apud Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág. 3190).

Acrescenta-se ainda que nos autos do processo nº 1503576452022826055400000, as conversas de Whatsapp, no celular de Lucas, filho do réu demonstram como o réu coordenava o tráfico, ordenava o fracionamento da droga, a contabilidade do tráfico e ainda há indicação de outros membros que integravam a associação ao tráfico e atividade de cada um deles, com estabilidade. Ademais, há foto da droga e como ela foi cortada.

Ressalta-se que o crime do art. 35 da Lei 11.343/06, dispõe: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não, qualquer dos crimes dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei.

Para Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol 1, p. 407, editora Forense, 2020, Rio de Janeiro afirma que para a configuração do delito exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe forma culposa.

Victor Eduardo Rios Gonçalves e José Paulo Baltazar Júnior explicam que: na prática, para fazer valer tal distinção, leva-se em conta o grau de organização, a gravidade da conduta e, evidentemente, a intenção de reiteração criminosa. Com efeito, quando existe essa intenção, não há dúvida de que está configurado o crime de associação para o tráfico (art. 35). Porém, quando não existir prova neste sentido, o julgador deverá verificar se existe certa organização dos envolvidos, bem como a forma como se comportaram no caso concreto. Assim, ainda que não tenham intenção de reiteração, se o juiz verificar, por exemplo, que eles se organizaram para, de uma só vez, importar e depois distribuir grande quantia de droga, responderão pelo crime autônomo (art. 35), evidentemente em concurso material com o tráfico por eles realizado (art. 33, caput). Igual conclusão deve ocorrer quando os agentes realizam várias condutas em relação ao mesmo objeto material, como por exemplo, quando plantam, cultivam, colhem, preparam e vendem um mesmo lote de entorpecente. (Legislação Penal Especial Esquematizado, 5ª ed. São Paulo; Saraiva, 2019., p. 212).

Portanto, restou, claramente, evidenciada a infração penal do art. 35 da Lei 11.343/06, conforme aos provas supracitadas, indicando as condutas praticadas pelo réu na associação ao tráfico.

Logo, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou a conduta delituosa descrita na denúncia.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e

de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Passo à dosimetria da pena com relação ao réu, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no art. 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que tendo em vista a grande quantidade de droga, mais de 40 quilos de maconha, localizada, fixo a pena base para o delito do art. 33, caput da Lei 11.343/06 em 5 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa. Para o delito do art. 35 da Lei 11.343/06 fixo a pena base em 3 anos de reclusão e o pagamento de 700 dias-multa.

Ressalto que no tocante ao delito previsto no artigo 33 caput", da Lei 11.343/06, a elevadíssima quantidade de drogas constitui circunstância que, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, incrementa o grau de reprovabilidade da conduta, autorizando uma pena mais rigorosa (STF, HC nº 96.655, rel. Min. Cármen Lucia; HC nº 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski ; STJ, HC nº 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; HC nº 235.524, rel. Min. Jorge Mussi; HC nº 223.447, rel. Min. Laurita Vaz, HC nº 179.086, rel. Min. Gilson Dipp, entre outros).

Na segunda fase de aplicação de pena, não há atenuante a ser considerada. Presente a agravante da reincidência (autos nº 00000065220178260441, 00133811920108260554 - fls. 46/49), razão pela qual, aumento a pena em 1/6 passando a pena do crime do art. 33, caput da Lei 11.343/06 a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 680 dias-multa e para o delito do art. 35 da Lei 11.343/06 em 3 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 816 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, levando-se em consideração que o agente é reincidente, hipótese que impede a incidência da referida causa especial de diminuição de pena. Ademais, não há que se alegar "bis in idem".

Neste sentido: "(...) ainda porque é o réu reincidente. 8. Reincidência e "bis in idem". Não há "bis in idem" no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena. Precedentes do STF (HC 107.274/MS Rel. Min. Ricardo Lewandowski 1ª T j. 12.04.11 DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura 6ª T j. 06.05.14 DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP Rel. Min. Laurita Vaz 5ª T j. 24.04.14 DJU 08.05.14). (Apelação 0025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017).

Por fim, os crimes do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 foram cometidos em concurso material, razão pela qual as penas devem ser somadas, totalizando 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 1496 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da ausência de informações seguras sobre a condição financeira do acusado.

Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida e a reincidência do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu CARLOS ALBERTO SERRANO, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput e 35 da Lei 11.343/06, c.c. art. 69 do Código Penal, a pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 1496 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que o levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita. Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 08 de agosto de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA